

1503039-84.2020.8.26.0274

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do(a) réu(ré), estaria traficando drogas no local em que o(a) denunciado(a) estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o(a) acusado(a) ter sido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

1ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapolis - SP - cep 14900-000

1503039-84.2020.8.26.0274 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503039-84.2020.8.26.0274

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Tiago Izaías da Silva e outro

Juiz de Direito: Dr. VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra TIAGO IZAIAS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Narra a inicial acusatória que, no dia 15 de outubro de 2020, por volta de 17h20, no interior do imóvel localizado na Rua Antônio Bernardino de Lima, n.º 139, bairro Jardim São Lucas, nesta cidade e comarca de Itápolis, o denunciado trazia consigo e guardava, para venda clandestina, bem como vendeu 3,80 gramas de maconha, acondicionada em três porções, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (fls. 164/165).

O réu foi devidamente notificado, apresentando resposta escrita às fls. 186/187. Denúncia recebida em 27 de abril de 2022, conforme decisão de fl. 194/200.

Inexistentes os motivos legais que ensejam a absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram inquiridas três testemunhas arroladas pela acusação, sendo, em seguida, interrogado o acusado. Após, o(a) representante do Ministério Público e o(a) defensor(a) apresentaram alegações finais orais.

Os autos me vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Das preliminares

Antes de proceder à análise do mérito, verifico que a defesa arguiu preliminar de nulidade das provas colhidas nos autos, ao argumento de que os policiais ingressaram na residência do denunciado sem autorização de seus ocupantes e sem mandado judicial.

Não há como acolher tal pleito.

Conforme restará adiante demonstrado, por ocasião da análise do mérito da imputação, na data dos fatos, policiais militares em patrulhamento pelas ruas do bairro Jardim São Lucas avistaram o acusado TIAGO no quintal de sua casa entregando um objeto para o usuário de drogas FIORINDO, que, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga.

Durante a fuga, FIORINDO colocou algo em sua boca, além de deixar cair algo ao solo. Os policiais conseguiram abordar FIORINDO logo adiante e identificaram o objeto que ele dispensou ao solo como sendo a sacola que lhe foi entregue por TIAGO, a qual continha em seu interior uma porção de maconha.

Em seguida, os policiais viram quando TIAGO colocou um “pino” dentro de sua cueca. Ele foi abordado e submetido a busca pessoal, apreendendo-se, em seu poder, a importância de R\$ 160,00 em espécie. Na cueca do denunciado foi apreendido o pino, mas ele estava vazio. Já dentro da casa, no freezer, foram apreendidas duas porções de maconha, sendo uma das porções acondicionada em invólucro idêntico àquele em que estava a porção que FIORINDO havia tentado se desfazer; a outra porção estava a granel. Sobre a geladeira, apreendeu-se uma balança de precisão, bem como um pote com pó branco. No quarto de TIAGO, dentro de uma fralda descartável, havia mais R\$ 385,00 em espécie.

Verifica-se, portanto, que havia fundadas razões (justa causa), devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, autorizadores da busca pessoal no acusado, bem como do ingresso em sua residência, ainda que sem mandado judicial, considerando-se o estado de flagrância.

Cumprе destacar que o tráfico de drogas, nas modalidades guardar, ter em depósito, expor à venda, transportar e trazer consigo, é crime permanente que, como tal, se protraí no tempo. Por essa razão, é prescindível a existência de mandado de busca e apreensão, mormente quando a atuação policial está amparada em fundadas razões (justa causa) que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito.

Em suma, quando o contexto fático anterior à busca pessoal permitir a conclusão acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas, é perfeitamente admissível a realização da prisão em flagrante, que poderá ser efetivada enquanto não cessar a permanência, independentemente de prévia autorização judicial.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016; AgRg no HC 651.377/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021; RHC 141.544/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021; HC 414.196/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017; HC 407.689/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017.

II.2. Do mérito

1. Analisando as alegações das partes, bem como os elementos de prova colhidos nos autos, verifico que o Ministério Público obteve êxito na comprovação dos fatos constitutivos da pretensão acusatória.

2. Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Ao Ministério Público incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua

pretensão. Ou seja, deverá provar a tipicidade, a autoria, as qualificadoras, agravantes, causas de aumento de pena e o elemento subjetivo do tipo (dolo). Em suma, "Toda informação que deponha contra o réu deve ser objeto de prova pelo acusador (público ou particular)" (FREITAS, Jayme Walmer de; SILVA, Marco Antônio Marques da. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 270). Por seu turno, a defesa possui o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória. Em outros termos, deverá demonstrar as excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade, privilégios, atenuantes, causas de diminuição de pena, etc. Em suma, incumbe-lhe demonstrar a existência de circunstâncias que impliquem em atenuação da pena ou na concessão de benefícios penais.

Cumprе ressaltar que o indício, espécie de prova indireta, é, sim, suficiente para a prolação de um decreto condenatório. Conforme esclarece Guilherme de Souza Nucci, "o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 632).

No caso do delito de tráfico de drogas, são indícios suficientes para a condenação do(a) agente, dentre outros: a) a confissão da prática do crime; b) a apreensão de substância entorpecente em poder do(a) autor(a) do fato e/ou de dinheiro em espécie (normalmente fracionado em notas miúdas, não possuindo o(a) denunciado(a) explicação convincente para a origem do numerário), bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do(a) réu(ré), estaria traficando drogas no local em que o(a) denunciado(a) estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o(a) acusado(a) ter sido flagrado por policiais em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes; e) a circunstância de o(a) acusado(a) ser conhecido no meio policial como traficante de drogas, responder a inquérito, já ter sido ou estar sendo processado, e/ou possuir condenação pela prática do referido delito. Em tais casos, ainda que o(a) autor(a) do fato não tenha sido flagrado comercializando entorpecentes, esses indícios (prova indireta) permitem que o magistrado conclua, em processo indutivo, ser ele(ela) traficante de drogas.

3. A materialidade delitiva foi comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 15/18), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), pelo auto de constatação de natureza de substância (fl. 21), pelo auto de exame de corpo de delito (fls. 25/30), pelos laudos periciais de substância entorpecente (fls. 106/113 e 138/155) e pelas demais provas encartadas nos autos.

4. A autoria é incontroversa.

Conforme narrado na denúncia, no dia 15 de outubro de 2020, por volta de 17h20, no interior do imóvel localizado na Rua Antônio Bernardino de Lima, nº 139, Bairro Jardim São Lucas, nesta cidade e comarca de Itápolis, o denunciado TIAGO IZAIAS DA SILVA trazia consigo e guardava, para venda clandestina, bem como vendeu 3,80 gramas de maconha, acondicionada em três porções, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

No dia do ocorrido, policiais militares em patrulhamento pelas ruas do bairro Jardim São Lucas avistaram o acusado TIAGO no quintal de sua casa, tendo entregado algo para uma pessoa identificada como FLORINDO.

Ao ver a viatura, FLORINDO correu e colocou algo em sua boca, além de deixar cair algo ao solo. Ele foi abordado pelos policiais, mas já havia engolido o que havia colocado na boca. O que ele deixou cair foi recolhido, constatando ser um sacolé com uma porção de maconha, que havia acabado de ser entregue por TIAGO.

Em seguida, os policiais viram quando TIAGO, já dentro de sua casa, colocou um "pino" dentro de sua cueca. Ele foi abordado e submetido a busca pessoal, apreendendo-se, em seu poder, a importância de R\$ 160,00 em espécie. Na cueca do

denunciado foi apreendido o pino, mas ele estava vazio.

Já dentro da casa, no freezer, foram apreendidas duas porções de maconha, sendo uma das porções acondicionada em saquinho idêntico ao que estava a porção que FIORINDO havia tentado se desfazer; a outra estava a granel. Sobre a geladeira, apreendeu-se uma balança de precisão, bem como um pote com pó branco. No quarto de TIAGO, dentro de uma fralda descartável, havia mais R\$ 385,00 em espécie.

Na residência também estava PRISCILA, companheira do denunciado, a qual aparentava nervosismo, chegando a entrar no banheiro. Com apoio da Guarda Civil Municipal feminina, PRISCILA foi submetida a revista e, em seu seio, foram apreendidos 34 saquinhos ziplock, idênticos aos que acondicionavam as drogas.

Vejam.

O acusado TIAGO IZAIAS DA SILVA, ao ser interrogado na fase policial, sustentou que "é usuário de maconha e cocaína e não está envolvido com o tráfico de drogas.

Questionado em relação a localização em sua residência de embalagens plásticas vazias, conhecidas por "zip-lock", balança de precisão, dinheiro, permaneceu em silêncio e não respondeu ao questionamento" (sic) (fl. 157).

Na audiência de instrução e julgamento, o denunciado TIAGO IZAIAS DA SILVA negou a autoria delitiva. Sustentou que as drogas apreendidas pelos policiais eram do interrogado, porém destinavam-se ao seu uso. O interrogado é usuário, não traficante, e por isso guardava as drogas na geladeira para melhor conservá-las. O dinheiro apreendido era proveniente de seu trabalho como servente de pedreiro. No dia dos fatos não foi trabalhar, pois havia chovido. Estava no interior de sua residência, quando os policiais chegaram, abrindo o portão, mesmo não tendo mandado judicial. FIORINDO não estava na casa do interrogado no dia dos fatos.

As testemunhas WILSON ROBERTO FURLAN e PEDRO PAULO RODRIGUES, policiais militares, ao serem inquiridos na fase policial, sustentaram que, "na tarde de hoje, por volta das 17 horas, estava em patrulhamento pelas ruas do Bairro Jd. São Lucas, quando avistou Thiago Izaias, na residência dele, estando com o portão do quintal aberto. O depoente pode ver quando Thiago entregou algo para Fiorindo Carrara. Fiorindo, ao ver a viatura, saiu correndo e colocou algo na boca, deixando cair alguma, coisa, também. Naquele momento Fiorindo foi abordado, mas ele já havia engolido o que tinha colocado na boca. O objeto que ele deixou cair foi recolhido, constatando ser um saquinho com uma porção de maconha. Em poder de Fiorindo, foi apreendido um telefone celular, que depois verificou tratar de produto de furto. Ato contínuo, entraram no quintal da casa de Thiago, e o depoente viu quando Thiago, já dentro de sua casa, colocou um 'pino' dentro de sua cueca. Thiago saiu da casa e foi abordado e submetido a revista pessoal, sendo apreendido, em seu poder, a importância de R\$160,00 em espécie. Na cueca de Thiago, foi apreendido o pino, mas ele estava vazio. Ato contínuo, entrou na casa e, dentro do freezer, foram apreendidas duas porções de maconha, sendo que, uma das porções estava acondicionada em saquinho idêntico a que estava a porção que Firmino havia tentado se desfazer. Sobre a geladeira, foi apreendido uma balança de precisão, com vestígio de drogas, bem como foi apreendido um pote com pó branco. No quarto de Thiago, foi localizado uma fralda descartável, dentro da qual estavam R\$385,00 em espécie. Na residência também estava Priscila, a qual aparentava nervosismo, chegando a entrar no banheiro. Com apoio da Guarda Civil Municipal feminina, Priscila foi submetida a revista e, em seu seio, foram apreendidos 34 saquinhos ziplock, idênticos a que aos que as drogas estavam acondicionadas. O telefone celular de Thiago foi apreendido" (sic) (fls. 03/04).

Ao serem inquiridas na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas WILSON ROBERTO FURLAN e PEDRO PAULO RODRIGUES sustentou que na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo Jardim São Lucas e avistaram o réu fazendo contato com Fiorindo no quintal da residência do réu. TIAGO entregou algo para FIORINDO, que, ao avistar a viatura, e saiu correndo. Na fuga, FIORINDO colocou algo na boca, bem como deixou cair um objeto no chão, que os depoentes apanharam e verificaram se tratar de um saco tipo ziplock contendo maconha. Adentraram o quintal da casa do réu e o viram colocando um pino de cocaína vazio na cueca. O réu também trazia consigo R\$ 160,00 em espécie. No freezer da geladeira, havia 2 porções de maconha, uma embalada em saco do tipo ziplock semelhante àquele dispensado por FIORINDO e outra a granel.

Em cima da geladeira, localizaram uma balança com resquícios de drogas, além de um frasco com pó branco. Em uma fralda havia R\$ 385,00 em notas trocadas. PRISCILA, esposa do réu, estava na casa, e muito nervosa. Solicitaram apoio da Guarda Municipal, cuja agente do sexo feminino localizou, no seio de PRISCILA, 34 ziplocks vazios. O réu já era conhecido nos meios policiais. Havia denúncias de tráfico de drogas no local. Em ocorrência anterior, o réu foi detido com cocaína e aproximadamente 5.000 eppendorf's. Não solicitaram autorização judicial para ingressarem na residência do réu. FIORINDO é conhecido por ser usuário de drogas. Quando empreendeu fuga, FIORINDO estava dentro do quintal do acusado, que estava com o portão aberto;

A testemunha FIORINDO CARRARA NETO, ao ser inquirida na fase policial, sustentou que "não foi à casa de Thiago na tarde de hoje, mas somente passou em frente e não conversou com Thiago. Que não correu dos policiais militares antes de ser abordado. Quando abordado, não colocou nada em sua boca e também nada jogou ao solo. A maconha apreendida pelos militares não lhe pertence. Que atualmente é usuário de maconha, mas somente a consome em sua casa. Quanto ao celular apreendido em seu poder, comprou-o na loja de celular, localizada atrás do colégio Moraes de Barros, conhecido, o vendedor, como 'Garotinho', pagando trezentos e cinquenta reais, mas não lhe foi entregue nenhuma nota fiscal. Que não sabia da procedência do aparelho" (sic) (fl. 07).

Ao ser inquirida na audiência de instrução e julgamento, a testemunha FIORINDO CARRARA NETO sustentou que no dia dos fatos estava descendo a rua da casa do réu. Ao chegar na esquina, os policiais o abordaram e o seguraram por aproximadamente 2h30 a 3h. Em seguida, os policiais entraram na casa do réu e os levaram até a Delegacia de Polícia. Não sabe porque foi abordado pelos policiais, que lhe disseram que o depoente havia saído da casa do réu. O depoente não é usuário de drogas. Não tem nada contra os policiais;

A testemunha PRISCILA APARECIDA LENGU, guarda municipal, disse que "que os policiais encontraram maconha no congelador da geladeira, mas ela era para uso do casal. Os policiais apreenderam dinheiro, que é proveniente do auxílio emergencial e parte do serviço de servente que THIAGO. Quanto aos saquinhos que estavam em seu poder, disse PRISCILA que era para sua amiga SILVANA, a qual utiliza para fazer bijuteria para unhas. Os policiais apreenderam uma balança de precisão, mas a declarante não sabe dizer para que ela é usada. Que a declarante e seu companheiro não vendem drogas" (fl. 157).

Ressalte-se que os depoimentos de policiais civis e militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão de ilícitos penais.

Além disso, é fato notório e de conhecimento geral que, nos crimes (e atos infracionais) de tráfico de drogas, impera a lei do silêncio, haja vista que a(s) testemunha(s) do fato, sentindo-se amedrontada(s) e temendo por sua integridade física e/ou de seus amigos e familiares, optam por se calar, por fornecer pouco(s) detalhe(s) a respeito da empreitada criminosa ou, simplesmente, por mentir à autoridade policial e/ou ao(à) magistrado(a). Em tal contexto, a(s) denúncia(s) anônima(s) e o(s) depoimento(s) de policiais civis e militares possuem grande valor probatório.

Registre-se que a testemunha FIORINDO CARRARA NETO é conhecido pelos policiais como usuário de drogas e, portanto, apresentou versão fantasiosa para os fatos para não ser incriminado, sendo pouco crível sua alegação de que teria sido abordado sem qualquer motivo pelos agentes de segurança. Por sua vez, PRISCILA APARECIDA LENGU é namorada do réu e foi abordada trazendo consigo, no interior do lar comum, objetos utilizados para a prática da traficância. Naturalmente possui interesse na absolvição de seu companheiro. Por essa razão, tais declarações, por si sós, são insuficientes para afastar a materialidade e a autoria delitivas.

5. Tendo em vista que inexistem causas excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, de rigor a condenação do(a) acusado(a).

6. A defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei de Tóxicos.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Nos termos do § 2º, do artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006, "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei de Tóxicos não exige que o agente seja flagrado praticando atos de mercancia para que sua conduta seja enquadrada no tipo penal do artigo 33, caput. Isso porque o delito de tráfico de drogas é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos núcleos do tipo ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas").

Conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, "para alicerçar a pretendida condenação por tráfico não é necessária a prova do comércio de substância entorpecente. O denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública" (TJSP; Apelação Criminal 1500705-48.2018.8.26.0274; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019 - grifo meu).

Ademais, a condição de usuário ou dependente de drogas não é incompatível com a figura do traficante, tampouco afasta per si a imputabilidade do agente. Nesse sentido: TJMS, HC 01733320620158110000, Relator: Desembargador Gilberto Giralddelli, DJ 04/02/2016; TJDF, APR 0015443-41.2008.807.0001, Relator: Desembargador Souza e Ávila, DJ 03/02/2010.

Cabe ainda ressaltar que, embora o réu foi flagrado comercializando entorpecentes, entregando uma porção de maconha para terceiro (FIORINDO). Além disso, estava em local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes; houve a apreensão de dinheiro em espécie, fracionado em notas miúdas, não tendo o denunciado(a) oferecido explicação convincente para a origem do numerário, bem como a apreensão de balança de precisão com resquícios de drogas; e, por fim, o acusado é conhecido no meio policial como traficante de drogas.

7. Acolho o pleito defensivo de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06. Para a aplicação do referido dispositivo legal é necessário que o Réu (i) seja primário, (ii) tenha bons antecedentes, (iii) não se dedique a atividades criminosas e (iv) não integre organização criminosa.

In casu, verifico que o acusado é primário e possui bons antecedentes.

Além disso, não há prova nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.

Com efeito, embora os policiais tenham afirmado que o réu é conhecido nos meios policiais como traficante e que há denúncias anônimas relacionando-o ao tráfico ilícito de entorpecentes, tais afirmações não foram corroboradas por outros elementos de provas. Ora, inexistem inquéritos policiais ou processos criminais em andamento (com denúncia oferecida e recebida) que tenham por objeto apurar o envolvimento do denunciado com o tráfico ilícito de entorpecentes em data anterior aos fatos que são objeto da presente ação penal.

Considerando-se que foi apreendida 3,80 gramas de maconha, reduzo a reprimenda em

II.3 - Da dosimetria das penas

1. Circunstâncias judiciais

Atentando para as diretrizes postas no caput do artigo 59 do Código Penal, caberá ao juiz, mediante fundamentação adequada e específica, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a reprimenda em patamar que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Considerando-se que não há critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; AgRg no RESp 1632832/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018; HC 473.777/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. Na mesma linha, são os seguintes precedentes do TJSP: Apelação 0066091-63.2016.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2017; Apelação 0005712-12.2017.8.26.0604; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018.

No caso dos autos, nenhuma das 8 (oito) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima) pode ser valorada negativamente.

Estabeleço a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Havendo circunstância agravante ou atenuante a ser isoladamente aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como regra a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento e para a diminuição, ressalvada fundamentação concreta que justifique a utilização de patamar superior, e respeitados os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada no preceito secundário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018; RESp 1738852/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; AgRg no RESp 1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017. Todavia, no caso de concurso de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observada a escala de preponderância prevista no artigo 67 do CP (circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência), aquela que estiver melhor graduada irá se sobressair (STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018; RESp 1285055/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Havendo concurso de majorantes e de minorantes, o artigo 68, § único, do Código Penal, estabelece as seguintes regras: a) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Geral, ambas deverão ser aplicadas,

desde que obrigatórias; b) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, o juiz poderá aplicar todas elas (desde que obrigatórias) ou limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou diminua; c) se existirem, ao mesmo tempo, 2 (duas) causas de aumento, ou então 2 (duas) causas de diminuição, previstas uma na Parte Geral e outra na Parte Especial ou legislação especial, todas elas serão aplicáveis.

De acordo com a doutrina, se existirem simultaneamente causa(s) de aumento e de diminuição de pena, todas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias. "Em primeiro lugar, o magistrado aplica as causas de aumento, e depois as de diminuição. Não pode a sentença fazê-las recair ao mesmo tempo, compensando-as" (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018, p. 398 - grifo meu).

Reconheço a minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006, motivo pelo qual reduzo a pena em 2/3. Fixo a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

4. Fixação do valor do dia-multa.

A ausência de informações acerca da situação econômica do réu, recomenda a fixação do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. Regime de cumprimento de pena.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena aberto, com fundamento nos artigos 33, §§ 2º, "c", e 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

6. Substituição por penas restritivas de direitos.

Considerando-se a quantidade de pena aplicada, que o agente não é reincidente específico e que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente (princípio da suficiência), substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em duas prestações pecuniárias, no valor de 1 salário mínimo cada uma, a entidade a ser designada pelo juízo da execução.

7. Suspensão condicional da pena.

Deixo de proceder à suspensão condicional da pena, porquanto o acusado já foi contemplado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ademais, prevalece no STF e no STJ o entendimento de que o sursis é inaplicável aos crimes hediondos ou equiparados, pois a dimensão do benefício não se coaduna com a natureza do delito, em relação ao qual a própria CF, em seu artigo 5º, XLIII, determinou tratamento mais severo (STF, HC 101.919/MG; STJ, HC 197.268/SP).

III - DISPOSITIVO

1. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar o(a) acusado(a) TIAGO IZAÍAS DA SILVA como incurso(a) nas sanções do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em duas prestações pecuniárias, no valor de 1 salário mínimo cada uma, a entidade a ser designada pelo juízo da execução.

2. Concedo ao(à) réu(ré) o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, não aportaram aos autos notícias de que o acusado tenha voltado a delinquir após os fatos objeto da presente ação penal. Ademais, não se acham presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

3. Outras disposições

Condeno o(a) acusado(a) ao pagamento das custas e despesas apuradas ao final. Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir prejuízo material constatado.

Transitada em julgado a sentença:

Inclua-se o nome do(a) condenado(a) no rol dos culpados.

Notifique-se o(a) condenado(a) para pagamento da multa no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 50 do CP;

Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 105 da Lei 7210/84;

Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD);

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF/88;

Porque não interessa a preservação das drogas apreendidas, oficie-se, determinando a incineração delas, mediante termo circunstanciado.

Demonstrado que o dinheiro apreendido era proveniente do tráfico de drogas, decreto seu perdimento em favor da União Federal, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/2006.

Procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Itapolis, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA